

1501518-97.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CARDOSO SANTANA DA SILVA

Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de Rafael Cardoso Santana da Silva, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501518-97.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501518-97.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CARDOSO SANTANA DA SILVA

Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de Rafael Cardoso Santana da Silva, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006, pelo seguinte fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 22 de julho de 2020, por volta das 14h00min, na Avenida Sargento da Aeronáutica Plínio F. Gonçalves, altura do nº 10, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, nas imediações da "Escola Estadual Soinco II", RAFAEL CARDOSO SANTANA DA SILVA, qualificado às fls. 18, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 15,7g (quinze gramas e

sete decigramas), e 39 (trinta e nove) invólucros plásticos contendo “Cannabis Sativa L”, substância popularmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 70,18g (setenta gramas e dezoito decigramas), substâncias entorpecentes causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 9/10; laudo de constatação de fls. 12/16).

Segundo se apurou, na data dos fatos, indiciado se encontrava pelo local dos fatos na posse das drogas acima descritas, praticando a traficância.

Ocorre que policiais militares foram acionados via COPOM, para averiguar uma possível prática de venda de entorpecentes, nas proximidades da Escola Estadual Soinco II, e se depararam com o indiciado, que, ao avistar a viatura, tentou se evadir, porém a equipe de patrulhamento logrou êxito na captura.

A acusação ofereceu a denúncia.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia por meio de da Defensoria Pública, reservando-se ao direito de alegar as teses de defesa em memoriais.

Rejeitou-se a referida defesa e recebeu-se a denúncia.

Não havendo qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução.

Citou-se o réu em audiência. Na audiência de instrução, colheram-se as declarações das testemunhas da acusação. Ainda, interrogou-se Rafael Cardoso Santana da Silva. O Ministério Público, em alegações finais, argumentou que “a ação merece ser julgada procedente. A materialidade do crime de tráfico vem estampada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação provisória de fls. 12/16, pelo mapa de fls. 88, que demonstra a proximidade do local dos fatos com um estabelecimento de ensino, e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 109/111. A autoria é certa e segura. O réu confessou a imputação. Ademais, os fatos foram devidamente comprovados pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuarão a prisão em flagrante, os quais confirmaram exatamente o quanto constante na peça acusatória. Com efeito, informaram que foram acionados via Copom para averiguar informação de tráfico de drogas no local, próximo à Escola Estadual Soinco II. No local, depararam-se com o réu, que, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas foi detido. Em revista pessoal, lograram encontrar em seu poder 34 porções de cocaína e 39 de maconha. Indagado, o réu confessou a traficância. Assim, foi ele preso em flagrante delito. Ante o exposto, postulo seja julgada procedente a presente ação penal, nos exatos termos da denúncia. Quanto à pena, em que pese a primariedade do réu (fls. 101/102 e 149/151), requeiro seja fixada acima do mínimo legal em razão da variedade e natureza das drogas apreendidas, bem como em razão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas. Em razão da primariedade do acusado, todavia, não nos opomos à redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei antitóxicos, e fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda. Já a defesa afirmou que: “DA PRELIMINAR – INQUIRIRÇÃO DIRETA: no ponto, deve-se salientar que a inquirição direta detalhada de vítimas e testemunhas, na contramão da cross examination consagrada pelo art. 212 do CPP, configura nulidade que macula a instrução e sobretudo o julgamento, conforme já sedimentado pelo Pretório Excelso, em especial no julgamento do HC 202.557. DA PRELIMINAR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: Em recentes julgados, esse Egrégio Tribunal de Justiça enfrentou a polêmica questão da incidência do acordo de não persecução na hipótese de tráfico privilegiado. Neles, reiterou-se o entendimento de que não incumbiria ao Poder Judiciário a sua propositura em face da recusa ministerial. Não obstante, a Egrégia Corte paulista vem firmando entendimento de que a recusa ministerial injustificada é passível de controle jurisdicional, sendo, no caso, hipótese de ausência de justa causa para a ação penal. Nessa esteira, importante ressaltar relevante precedente da Colenda 16ª Câmara, relatado pelo nobre Desembargador e Professor Marcos Alexandre Coelho Zilli, no bojo do Recurso em Sentido Estrito nº 0000781-42.2021.8.26.0695: “6. Recusas infundadas ou desarrazoadas comportam correção não se podendo retirar do Judiciário o exame sobre a lesão ou ameaça de lesão, mormente quando esta envolver a liberdade. Não se concebe que o Ministério Público, como

ator igualmente responsável pela concretização de políticas criminais, não apresente justificativa para a recusa do uso da via consensual ou que apresente justificativa não amparada pela própria lei. 7. Não haverá interesse de agir - necessidade - no uso da via disputada, enquanto não esgotada a possibilidade do uso da via consensual. Logo, o interesse de agir do órgão acusador na promoção da ação penal vincula-se, igualmente, ao esgotamento do interesse primário do Estado no uso da justiça consensual. Nessa quadratura, o controle judicial posta-se como impedimento ao exercício da ação penal, seja pela via da rejeição liminar (art. 395 do CPP), seja pela via do trancamento da ação penal, reconhecendo-se, dessa forma, o constrangimento ilegal pela inobservância das políticas criminais de harmonização dos espaços de intersecção entre o modo consensual e o modo disputado de realização de justiça". Vejamos, também, excerto do v. Acórdão proferido pela Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal no bojo de julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1504864-70.2021.8.26.0228, que segue no mesmo sentido: "Contudo, ao constatar que a recusa foge das hipóteses legais, o magistrado não pode quedar-se inerte e silente, validando recusa imotivada, sendo necessário reconhecer a ausência de justa causa para propositura da ação penal, nos moldes da decisão impugnada, como bem pontuado pela Defensoria Pública [...]". Por conseguinte, verifica-se que, no presente caso, houve recusa injustificada de oferecimento pelo I. Ministério Público ante posicionamento institucional consolidado, sendo exatamente a hipótese dos precedentes acima mencionados. Nesse sentido, requer-se o reconhecimento, ainda que nesta fase processual, da ausência de justa causa decorrente da recusa injustificada na propositura de acordo de não persecução penal, rejeitando-se a Denúncia com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

DO MÉRITO

PROBATÓRIO: com o devido respeito, inexistente prova segura para fins de condenação. Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública, sejam policiais civis, militares, agentes penitenciários ou mesmo guardas civis metropolitanos devem ser tomados, sempre, com a mais absoluta cautela e parcimônia, considerando não apenas o interesse que estes costumeiramente possuem no desfecho condenatório, como também o fato de que o elevado número de ocorrências e o estresse cotidiano não raras vezes lhes prejudicam a melhor lembrança da dinâmica dos fatos, podendo-se falar até mesmo de confusões entre umas ocorrências e outras, naturalmente. Quanto ao interrogatório, saliente-se que, em juízo, o acusado admitiu a prática delitiva, o que, isoladamente, não pode embasar um decreto condenatório. Por tudo isso, de rigor a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

HIPÓTESE CONDENATÓRIA - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: pugna-se pela fixação da pena-base no mínimo patamar legal, uma vez que as circunstâncias judiciais são usuais à espécie, não sendo mais elevada do que o cotidianamente verificado nem a quantidade e nem a variedade, havendo pacífica Jurisprudência do E. TJSP e do C. STJ nesse sentido. Na segunda fase, deve ser atenuada a pena em virtude da confissão e da menoridade relativa, compensando-se quaisquer acréscimos nesta fase ou na anterior. Na terceira fase, deve ser afastada a majorante da proximidade com estabelecimento de ensino. Isso porque os fatos teriam ocorrido em 22 de julho de 2020, auge da pandemia do novo coronavírus, quando todas as escolas estavam fisicamente fechadas em virtude das medidas sanitárias de isolamento social, havendo apenas aulas online. Nesse sentido, cabe recordar ser esse o entendimento do C. STJ, cabendo destacar, ainda, o julgamento paradigmático do HC 728.750. Saliente-se, ainda, que a retomada das aulas presenciais no Estado de São Paulo se deu apenas a partir de dezembro de 2020, na forma do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020 (disponível em <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65384-17.12.2020.html>). Ainda na terceira fase, de rigor a minoração em grau máximo pela figura do tráfico privilegiado, uma vez que o réu preenche integralmente os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, inexistindo quaisquer fundamentos concretos a afastar sua incidência ou, ainda, justificar uma redução aquém do patamar máximo legal. O regime inicial, considerando a pena esperada, a primariedade e a boa antecedência do acusado, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser o aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Avançando, pede-se seja garantido o recurso em liberdade, uma vez que o acusado respondeu solto a todo o processo, inexistindo qualquer

alteração do quadro fático-jurídico. Por fim, pede-se a isenção das custas, uma vez ser pessoa pobre na acepção legal do termo, defendido pela Defensoria Pública ao longo de todo o processo".
É o relatório.

Fundamentação

Das preliminares

Não há nulidade quanto à condução da audiência.

Decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no HC n. 202.557:

Habeas corpus. Impetração que figura como sucedâneo de revisão criminal. Não conhecimento. Concessão da ordem de ofício. Possibilidade. Ilegalidade flagrante verificada no caso concreto. Atuação do juiz e ordem de inquirição de testemunhas.

Art. 212 do CPP. Ausência de justificativa apta a afastar a incidência de norma cogente e de aplicabilidade imediata. Violação ao princípio do devido processo legal. Atuação ativa e de protagonismo desempenhada pelo juízo a quo na inquirição de testemunhas de acusação. Afronta ao princípio acusatório. Comprometimento ao actum trium personarum. Utilização de depoimentos colhidos em descompasso com a legislação de regência para fundamentar o decreto condenatório. Prejuízo demonstrado. Réu custodiado em decorrência de sentença ora reputada nula.

Restituição ao status libertatis que se impõe. Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade da ação penal originária a partir da audiência de instrução e julgamento e determinar a imediata soltura do paciente.

1. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.

2. A separação entre as atividades de acusar e julgar não autoriza que o juiz, em substituição ao órgão de acusação, assumo papel ativo na produção probatória, sob pena de quebra da necessária imparcialidade do Poder Judiciário.

3. O processo penal é instrumento de legitimação do direito de punir do Estado e, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais.

4. No que tange à oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento, deve o magistrado, em atenção ao art. 212 do CPP, logo após a qualificação do depoente, passar a palavra às partes, a fim de que produzam a prova, somente cabendo-lhe intervir em duas hipóteses: se evidenciada ilegalidade ou irregularidade na condução do depoimento ou, ao final, para complementar a oitiva, se ainda existir dúvida - nessa última hipótese sempre atuando de forma supletiva e subsidiária (como se extrai da expressão "poderá complementar").

5. A redação do art. 212 é clara e não encerra uma opção ou recomendação. Trata-se de norma cogente, de aplicabilidade imediata, e, portanto o seu descumprimento pelo magistrado acarreta nulidade à ação penal correlata quando demonstrado prejuízo ao acusado.

6. A demonstração de efetivo prejuízo no campo das nulidades processuais penais é sempre prospectiva e nunca presumida. É dizer, não cabe ao magistrado já antecipar e prever que a inobservância a norma processual cogente gerará ou não prejuízo à parte, pois desconhece quo ante a estratégia defensiva.

7. Demonstrado, no caso dos autos, iniciativa e protagonismo exercido pelo Juízo singular na inquirição das testemunhas de acusação e verificado que foram esses elementos considerados na fundamentação do decreto condenatório, forçoso reconhecer a existência de prejuízo ao acusado.

8. O Juízo a quo ao iniciar e questionar detalhadamente a testemunha de acusação, além de subverter a norma processual do art. 212 do CPP, violando a diretiva legal, exerceu papel que não lhe cabia na dinâmica instrutória da ação penal, comprometendo o actum trium personarum, já que a "separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional" é consectário lógico e inafastável do sistema penal acusatório

(ADIMC 5.104, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.5.2014).

9. Habeas corpus concedido de ofício a fim de reconhecer a nulidade da ação penal originária a partir da audiência de instrução e julgamento e, como consequência, restituir a liberdade ao acusado, a fim de que responda solto à instrução da ação penal que deverá ser renovada.

(HC 202557, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 3/8/2021, sem negrito no original)

O julgamento deixa claro que: a) não cumpre ao magistrado detalhar, logo de início, a instrução probatória no que toca às testemunhas; e, b) é preciso que se demonstre o prejuízo na inquirição para que seja reconhecida nulidade.

No caso em tela, não houve questionamento detalhado da testemunha de acusação. Pelo contrário. Houve leitura breve dos fatos narrados na denúncia e, então, pergunta genérica e feita a todas as testemunhas pelo juízo (sejam arroladas pela acusação ou defesa): “O que o(a) senhor(a) sabe sobre esses fatos?”. Tal pergunta genérica não foi e nunca será seguida de qualquer outra pergunta do magistrado. Ao momento em que a testemunha termina o relato livre (completo ou não, suficiente ou não), transfere-se a palavra à parte que arrolou a testemunha (ou, sendo comum, à acusação).

Trata-se, na realidade, de busca por um depoimento inicial livre de qualquer interferência das partes. O relato livre é mais fidedigno e confiável. A pergunta genérica, como feita acima, não induz qualquer resposta; não contém em si uma resposta; e é indicada pela ciência do testemunho como a melhor forma de iniciar qualquer inquirição. Permite à testemunha invocar as memórias que tem na ordem que as lembra, sem que o juízo ou as partes interfira nesse processo.

Considerando a relevância da prova testemunhal no Direito Criminal, é essencial que se busquem estratégias para que tal forma probatória seja colhida com o mínimo de interferência possível no processo de comunicação do que a testemunha viu e ouviu. Certo, pois, que a realização de pergunta genérica não viola o decidido HC 202.557 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, dá a tal entendimento concretude, visto que não importa no detalhamento da inquirição da testemunha pelo magistrado; e, ao mesmo tempo, permite obter da testemunha relato inicial fidedigno, livre de qualquer influência.

Em razão do exposto, rejeito a preliminar alegada.

No que toca à ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal, depende de vontade institucional do Ministério Público. É o que se interpreta da utilização do termo “poderá” no art. 28-A do CPP. E, ainda, da avaliação dos requisitos de “necessidade” e “suficiência” também trazidos pelo mesmo dispositivo.

Ademais, a Lei Federal n. 13.964/2019 previu expressamente, que na hipótese de o órgão acusatório não ofertar acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior.

Estabelecidas tais premissas, no caso em tela não houve manifestação de inconformismo em momento oportuno. Ainda, o oferecimento da denúncia faz presumir a inexistência de vontade institucional do Ministério Público para a realização de acordo de vontades para o não oferecimento da denúncia (acordo de não persecução penal).

Em razão do exposto, rejeito a preliminar alegada.

Do mérito

Presentes, assim, as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à análise do mérito.

Diz o art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O tipo objetivo, portanto, consiste na prática de qualquer dos verbos (bastante um)

acima expostos com substância definida na Portaria SVS/MS n. 344/1998. Tratando-se de tipo misto alternativo, basta a prática da conduta descrita em um único verbo.

A prova da materialidade é indubitosa. Está no boletim de ocorrência (fls. 6/8); no auto de exibição/apreensão (fls. 9/10); e nos laudos de constatação (fls. 12/16 e 109/111). Está, também, na confissão do réu.

No que toca à autoria, o réu confessou.

Em seu interrogatório, o réu Rafael Cardoso Santana da Silva

alegou que, realmente, estava traficando e era a primeira vez; que tinha começado aquele dia à tarde; que o local era perto da escola; que é lá em cima; que é mais de uma quadra; que a escola estava fechada devido à pandemia; que estava com cocaína e maconha; que as porções eram para a venda;

A testemunha Edson da Conceição, policial militar, esclareceu que foram solicitados via copom; que o copom informou para a equipe que havia um indivíduo na prática de entorpecentes pela via; que disseram que ele estaria na prática de tráfico; que, quando o indivíduo avistou a viatura, empreendeu fuga por alguns metros; que obtiveram êxito na abordagem e o réu estava com certa quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína); que estava bem próximo da escola Soinco II; que, quando preso, o réu confessou a prática e falou que tinha começado a pouco tempo; que nunca tinha visto o réu; que não se recorda como estavam os entorpecentes; que estavam nas vestes.

A testemunha Fernanda da Silva Araújo, policial militar, afirmou que, no dia em questão, receberam uma denúncia via copom; que foram averiguar o fato; que adentraram a via, visualizaram o indivíduo nas características; que tentou fugir e foi abordado; que o local era próximo a uma escola, na mesma via; que, salvo engano, é a Soinco II; que tinha porções de mais de um tipo de droga (maconha e cocaína); que falou que estava há pouco tempo no local trabalhando no tráfico; que não se recorda se as escolas estavam abertas; que as porções de entorpecente estavam em papéletes; que encontraram as porções nas vestes do indivíduo; que a escola é na mesma via, dá uns 200 metros.

A confissão, por si só, sem outros elementos indiciários ou probatórios, é insuficiente para ensejar édito condenatório. Não é, todavia, o caso em tela, já que as testemunhas corroboraram o que narrou o próprio réu: que trazia consigo os entorpecentes descritos na denúncia e que se destinavam ao comércio.

Ainda, não há que se falar em invalidade do depoimento dos policiais. Houve oportunidade para que a defesa fizesse perguntas que pudessem, eventualmente, demonstrar que não se lembravam do caso ou, de qualquer outra forma, evidenciar contradições. E, oportunizado tal momento, nada se apurou que tornasse seu depoimento pouco crível.

É certo, portanto, que o delito ocorreu e foi praticado pelo réu.

A tipicidade objetiva está provada. O laudo toxicológico indicou a substância como sendo maconha (THC) e cocaína. E tais substâncias constam da Portaria SVS/MS n. 344/1998.

No que toca à mercancia, está demonstrada pelos elementos dos autos. Dentre eles, a confissão; o fato de que o réu havia adquirido quantidade suficiente e variada de entorpecentes de uma vez, mesmo não sendo pessoa abastada e a forma de embalagem das substâncias.

O crime se consumou porque de mera conduta.

Há prova do dolo, já que o fato foi praticado com consciência e vontade de agir.

Há, portanto, tipicidade subjetiva.

Houve violação do bem jurídico protegido pela norma, qual seja a saúde pública, já que quantidade encontrada é suficiente para o consumo e para o tráfico. Presente, pois, a tipicidade material.

Presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento realizado pelo réu. Isso se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes desses elementos do conceito analítico de crime.

Enfim, comprovada a materialidade e autoria do fato, essa recaindo sobre o réu Rafael Cardoso Santana da Silva; sendo típica a conduta de trazer consigo,

capitulada no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006; e não militando em favor dele qualquer circunstância que exclua o crime ou o isente de pena, imperativa a condenação.

Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão. O réu FULANO era menor ao tempo dos fatos (art. 65, I, CP). Ainda, o réu confessou os fatos e usou-se sua confissão para a formação do édito condenatório (art. 65, III, d, CP)

Não há agravantes.

Em relação às causas de aumento de pena, com razão a defesa sobre a inaplicabilidade do art. 40, III, da Lei de Drogas. O fim de tal norma é proteger com mais ênfase o bem jurídico quando o autor do fato se aproxima de escolas para realizar a venda de entorpecentes a alunos. No caso, todavia, a escola encontrava-se fechada em razão da pandemia. Não há, pois, mais grave ofensa ao bem jurídico saúde pública que justifica a majoração da pena.

No que toca às causas de diminuição de pena, presente aquela descrita no § 4º. Não há prova de que o réu seja reincidente, tenha maus antecedentes, dedique-se às atividades criminosas ou seja membro de organização criminosa. Cabível, pois, a aplicação do privilégio em sua fração máxima.

Dosimetria da pena

Nos termos do art. 68 do CP, passo a fixar a pena do réu para o crime cometido. Anoto, desde já, para que não haja dúvida, que, buscando critério razoável para o uso da discricionariedade judicial, que o cálculo da pena base quando houver reconhecimento de circunstâncias será feito com base no critério, em regra, de um décimo da diferença entre a pena mínima e o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima.

Diz-se “em regra” porque, nos casos em que a circunstância for mais ou menos importante, será sopesada de outra forma, mediante justificativa específica.

Usa-se décimo porque esse é o número de circunstâncias a se analisar.

A base de cálculo é o termo médio entre a pena mínima e o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima porque: a) é necessário respeitar o intervalo fixado pelo Poder Legislativo no uso de sua competência; e, b) ainda será necessário dosar a pena na segunda fase, quando ela está limita a um teto, de maneira que não se pode considerar todo o intervalo como passível de preenchimento por meio das circunstâncias na primeira fase.

O grau de reprovabilidade da conduta é normal à espécie delitiva, sendo normal a culpabilidade. Quanto aos antecedentes, não há. Não há elementos hábeis para avaliar sua conduta social e sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto. Quanto aos motivos, agiu pelo desejo que já é valorado pelo tipo. As circunstâncias do crime não militam em desfavor do réu. As consequências do delito são as que já se encontram abarcadas no tipo em questão. Não há que se falar em vitimologia neste caso. A quantidade das substâncias era suficiente para caracterizar o tráfico, mas usual para tal tipo de conduta. A droga tinha natureza excepcional (cocaína, com maior poder viciante).

Assim, entendendo como suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime sob julgamento, diante das circunstâncias judiciais, sendo uma desfavorável ao acusado, fixo inicialmente a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Houve confissão no interrogatório (art. 65, II, “d”, do CP), a qual foi utilizada como fundamento da condenação.

Rafael Cardoso Santana da Silva era menor à época dos fatos (art. 65, I, CP). Todavia, a incidência de atenuante não pode reduzir a pena a valor inferior ao mínimo legal (enunciado da Súmula n. 231 do STJ).

Em razão disso, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há causas de aumento de pena. Aplica-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na quantia de dois terços.

Razões pelas quais fixo a pena final do art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006 para Rafael Cardoso Santana da Silva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa, nos termos do art. 49, § 1º, do CP em 1/30 do salário-mínimo de 2020 (ano em que ocorreu o fato criminoso), tendo em vista que ausentes nos autos elementos demonstrando que Rafael Cardoso Santana da Silva auferia renda superior a um salário-mínimo mensal.

Apesar de ter ocorrido breve prisão de Rafael Cardoso Santana da Silva, de maneira que seria o caso de se promover a detração, na forma do art. 42, do CP, verifico que não será suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena. Razão pela qual deixo de promovê-la nesse momento, postergando-a para a fase de execução. Estabeleço como regime inicial para o cumprimento da pena o regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, tendo em vista que a pena é inferior a 4 anos, Rafael Cardoso Santana da Silva não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Considerando a natureza do delito (não hedionda, visto que privilegiado), a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais, substituto a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, in fine, do CP), optando pela prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (arts. 43, IV, e 46, § 3º do CP); e a limitação de fim de semana.

A entidade beneficiada será oportunamente designada.

Deixo de promover a suspensão condicional da pena, visto que cabível a substituição (art. 77, III, CP).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da denúncia para condenar o réu Rafael Cardoso Santana da Silva nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, com pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto (a qual se substitui por duas penas restritivas de direitos, quais sejam a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana) e 166 dias-multa (com o valor de 1/30 do salário-mínimo de 2020).

Por fim, quanto ao entorpecente apreendido, caso tal providência ainda não tenha sido adotada, determino sua incineração, por não mais interessar ao deslinde do presente feito. Oficie-se ao Delegado de Polícia onde a substância está armazenada para que realize a diligência nos termos do art. 50, §§ 4º e 5º, da Lei Federal n. 11.343/06, juntando termo circunstanciado ao feito, no prazo de 30 dias.

Deixo de arbitrar honorários ao defensor do réu, posto que Defensoria Pública.

Ainda, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). Defiro a ele o benefício da gratuidade da Justiça, já que presentes seus pressupostos.

Anote-se.

Ante a fixação do regime inicial aberto, com conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o qual se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade, revogo as medidas cautelares arbitradas em desfavor do réu (art. 316, CPP). Por consequência, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Não há o que se falar em fixação de valor mínimo para reparação de danos no presente caso (art. 387, inciso IV, do CPP), porque não há vítima.

Não há vítima. Assim, desnecessária a comunicação na forma do art. 201, § 2º, do CPP.

Após o trânsito em julgado da sentença:

Caso exista pena de multa, providencie o Cartório, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe.

Cumpra-se, no mais, o que dispõe as Normas de Serviço Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, pelo Portal Eletrônico.

P., r. e i..

Guarulhos, 25 de julho de 2022.

Pablo Rodrigo Palaro de Camargo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA